

1502845-22.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.1.) A quantidade de entorpecentes apreendidos separados em porções individuais, a denúncia acerca do tráfico no local dos fatos e as anotações relacionadas ao comércio espúrio, comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.2.) Neste ponto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502845-22.2021.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502845-22.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2334435/2021 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 21847333 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 3099/21/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2334435 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos, etc.

1.) Propõe o MINISTÉRIO PÚBLICO AÇÃO PENAL em face de GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos autos. Alega o autor que, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 16h00, na Rua Porto Rico, 100, Centro, na cidade e comarca de Santana de Parnaíba, o réu guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 12 unidades de maconha (peso líquido de 31,25g) e 18 unidades

de crack (peso líquido de 1,28g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Consta, ainda, da denúncia que, nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rua Domingos Fernandes, Nº 534, Cristal Parque, neste município, o réu possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munição de arma de fogo de uso permitido (uma munição de revólver recarregada, de calibre .38), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.2.) Segundo a exordial acusatória, o denunciado GABRIEL decidiu levar a cabo o comércio ilícito de drogas. Para tanto, dirigiu-se ao local dos fatos em posse de maconha e crack, devidamente embalados em porções individuais, prontos para venda em varejo.

1.3.) Ocorre que, na data acima mencionada, guardas civis municipais receberam denúncia anônima versando sobre a prática de tráfico e se dirigiram ao endereço para averiguação.

1.4.) Chegando ao local dos fatos, os servidores públicos procederam à abordagem de GABRIEL e de outro indivíduo posteriormente identificado como Douglas da Silva Félix.

1.5.) Ao ser indagado, o denunciado logo afirmou que exercia a função de disciplina no bairro, sendo o responsável pelo comércio de entorpecentes no local. Na sequência, pediu que Douglas mostrasse aos guardas municipais onde estavam armazenados os entorpecentes, os quais foram localizados e apreendidos a cerca de 05 (cinco) metros de onde foi realizada a abordagem.

1.6.) Ademais, GABRIEL confessou que guardava em sua residência, situada à Rua Domingos Fernandes, Nº 534, Cristal Parque, neste município, objetos de interesse policial. Os guardas municipais, então, rumaram até o local e, com a permissão do denunciado, ingressaram no imóvel e localizaram 1 porção de maconha, além de papéis contendo anotações do tráfico e uma munição de revólver recarregada, de calibre .38.

1.7.) Diante de tal circunstância, os guardas municipais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram à Delegacia de Polícia.

1.8.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e Art. 12, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

2.) Constam do inquérito policial o auto de prisão em flagrante (fls.05/06), o boletim de ocorrência (fls.07/10), o auto de exibição e apreensão (fls.18/19) e o laudo de constatação (fls.28/31).

2.1.) O laudo toxicológico definitivo foi acostado às fls.140/142, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e crack.

3.) Notificado, o apresentou defesa prévia (fls.88/92), mas, a decisão de fls.99/102 recebeu a denúncia.

4.) Em instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes (fls.171/173).

4.1.) Interrogado, o réu negou a prática delitiva aduzindo que estava cortando o cabelo, momento em que ele e Douglas, seu barbeiro, foram abordados por guardas municipais. Em seguida, os guardas lhe colocaram dentro da viatura e o levaram até sua residência, vindo a ingressar no imóvel com a chave do local fornecida anteriormente por sua namorada. Acrescentou não ter acompanhado o ingresso dos

guardas no imóvel, tampouco o encontro fortuito dos entorpecentes (fls.170).

5.) Vieram alegações finais por memoriais, quando a acusação pugnou pela procedência parcial da ação com a absolvição pela atipicidade material do crime de porte de munição. Na dosimetria do crime de tráfico, requereu a fixação da pena acima do mínimo legal dadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a exasperação pela reincidência e inaplicabilidade do tráfico privilegiado. Ainda, pugnou pela fixação do regime inicial fechado (fls.184/191).

6.) O réu, por memoriais, pugnou pela absolvição ante a fragilidade do conjunto probatório (fls.213/217).

É o relatório.
Fundamento.

7.) Com efeito, o tráfico de entorpecentes possui natureza permanente, dispensado a expedição de prévio mandado de busca e apreensão durante a ação policial.

7.1.) Existindo fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito, nada impede que a autoridade policial penetre na residência do agente, a qualquer hora, sem estar munida de ordem judicial, sendo eventuais abusos apreciados posteriormente. Contudo, não foi o que se verificou no caso vertente, eis que a denúncia recebida anteriormente ao fato justificou a ação. Neste sentido:

Revisão criminal - Tráfico de drogas - Pretendida a anulação do processo por ilicitude da prova produzida - Impossibilidade - Não há falar em nulidade processual sob o argumento de violação de domicílio ou da ilicitude das provas por derivação, máxime porque nada impede que policiais adentrem em residência alheia, seja durante o dia ou a noite, contra a vontade do morador, para efetuar prisão em flagrante - Crime permanente - Nulidade afastada - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Inadmissibilidade - Descabida a rediscussão e a reanálise de provas - Ação revisional que não pode, sem nenhum elemento probante novo, rescindir o julgado condenatório - Tema suficientemente analisado em ambos os graus de jurisdição, pelo que não se admite alterá-lo por meio da revisão criminal - Via impugnativa que não deve ser manejada como se fosse nova apelação, sem nenhum amparo legal. Ação revisional não conhecida.

(TJSP; Revisão Criminal 2291620-46.2021.8.26.0000; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Data do Julgamento: 23/03/2022)

8.) No mérito, a ação é parcialmente procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu guardava e tinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 12 unidades de maconha (peso líquido de 31,25g) e 18 unidades de crack (peso líquido de 1,28g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10.) A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.05/06), pelo boletim de ocorrência (fls.07/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls.18/19), pelo laudo de constatação (fls.28/31), pelo laudo toxicológico definitivo, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas tratavam-se de maconha e crack (fls.140/142), a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local, não obstante a lúdica e inverossímil versão apresentada em juízo. Vejamos.

11.1.) Marcelo, guarda municipal, ouvido às fls.172, relatou que receberam denúncias acerca do tráfico na região dos fatos e, durante o patrulhamento, avistaram dois indivíduos, os quais foram abordados. Durante a revista pessoal,

nada de ilícito foi encontrado com o réu, contudo, ele confessou informalmente que traficava no local, sendo o "sintonia" da região, enquanto Douglas informou que era usuário e que havia adquirido o entorpecente do réu. Ainda, acrescentou que o réu indicou onde se encontravam os entorpecentes e informou que em sua residência estavam anotações do tráfico. No imóvel, foram localizadas as anotações e uma munição. Nesta toada, temos o depoimento de Tiago, também guarda municipal, tendo este acrescentado que o réu afirmou pertencer ao PCC.

11.2.) Consigne-se que o depoimento dos policiais decorre de ato de ofício dos agentes da Lei, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.3.) Douglas, ouvido às fls.173, aduziu ser barbeiro e que, enquanto se preparava para cortar o cabelo do réu, eles foram abordados pelos guardas municipais . Aduziu que estava com 13 pedras de crack para seu uso próprio, pois, as utilizaria ao longo do dia.

12.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico não havendo que se falar em absolvição.

12.1.) A quantidade de entorpecentes apreendidos separados em porções individuais, a denúncia acerca do tráfico no local dos fatos e as anotações relacionadas ao comércio espúrio, comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico.

12.2.) Neste ponto, cumpre destacar que a versão apresentada pelo acusado de que os guardas municipais teriam a chave de sua residência, vindo a forjar entorpecentes e anotações do tráfico no local, restou isolada nos autos, sendo afastada pela prova produzida sob o crivo do contraditório, bem como pelo depoimento de Douglas quando ouvido pela Autoridade Policial, o qual teria afirmado que comprou do réu uma pedra de crack, por R\$ 5,00 (fls.16).

13.) No que se refere à posse irregular de munição, dada a natureza da conduta, de rigor o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da ausência de lesividade social, pois, apreendida uma única munição calibre .38, no interior da residência do réu, desacompanhada de arma de fogo. Neste sentido:

APELAÇÃO. Recepção e posse de munição de uso permitido. Recurso defensivo. Indícios colhidos na fase investigatória que não foram confirmados em juízo. Jogos eletrônicos que não foram devidamente identificados. Existência de dúvidas quanto à origem ilícita. Posse irregular de munições de uso permitido. Reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de lesividade. Apreensão de apenas três munições de arma de fogo que não apresenta relevância jurídica. Jurisprudência do E. STF. Absolvição que se impõe. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0011165-89.2017.8.26.0635; Relator (a): Leme Garcia;; Data do Julgamento: 11/05/2021)

14.) Inexistindo discriminantes e causas de exclusão de culpabilidade a se apreciar,

Decido.

15.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para:

a) CONDENAR o réu GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA como incurso no Art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06; e

b) ABSOLVER-LO do crime previsto no Art. 12, da Lei n.º 10.826/06, com fulcro no Art. 386, III, do CPP.

Passo a dosar a pena

16.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente. No caso, a culpabilidade não ultrapassa aquela prevista no tipo penal.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente específico, o que será analisado oportunamente.

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base do tráfico. Neste sentido: TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018.

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico. No caso, GABRIEL, mesmo diante do direito constitucional de permanecer calado, demonstrou personalidade audaciosa e optou pelo perjúrio, mentindo em juízo sobre o crime a ele imputado, tentando incriminar os guardas municipais responsáveis por sua prisão, aduzindo que os agentes da lei teriam obtido a chave de sua residência, vindo a plantar os entorpecentes e as anotações do tráfico no interior do imóvel, o que revela grave falha de caráter e óbvia intenção de frustrar a responsabilização pelos seus graves atos.

d.1.) Neste ponto, como bem destacado pelo promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis, oportuno transcrever a crítica de NELSON HUNGRIA ("A diagnose da mentira" in Novas Questões-Jurídico Penais, Editora Nacional de Direito, 1945, p. 233), que já asseverava, com grande veemência, "que, desgrazadamente, a mentira é um dos mais constantes fatores de perturbação da Justiça Criminal ou um dos mais eficientes recursos tendentes à impunidade dos que delinquem. Sempre foram fiéis aliados o crime e a mentira". (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: . Acesso em: 8 fev. 2019.

d.2.) É certo que o direito ao silêncio, facultado ao réu a fim de evitar que se autoincrimine (nemo tenetur se detegere), encontra respaldo na Constituição Federal (CF, art. 5º, LXIII). Todavia, dele jamais se pode extrair o direito de mentir, pois, a mentira representa verdadeira fraude processual, não podendo o Estado ser complacente com este tipo de comportamento vil e abjeto, que pode levar ao erro judiciário, desmoralizando, assim, a própria Justiça. Uma coisa é permanecer em silêncio, ato nitidamente omissivo; outra bem diferente é mentir e acusar outros de mentirosos, conduta altamente ativa, antiética e contrária aos valores mais mezinhos da sociedade, não nos parecendo, assim, que exista uma garantia ao suposto direito.

d.3.) Como bem pontuou o colega Fernando Augusto Chacha de Rezende, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás: "(...) se a pena deve ter caráter, eminentemente, ressocializador (vertente dúplice – prevenção geral/especial e repreensão) maior penalidade deve ter aquele que deixa de utilizar-se de instituto legítimo e constitucionalmente previsto da não autoincriminação (silêncio) para, inadvertidamente, obter (em conduta positiva) situações que destoem, por

completo, da realidade fática probatória.” (Revista Consultor Jurídico, 20 de setembro de 2017, 12h00). Neste sentido:

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, ...) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta. Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se. Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade. Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, conseqüentemente, fica sujeito a valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa. Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da auto-defesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional. Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária a convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inverdade podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade” (TJSP; Apelação Criminal 9056896-37.2005.8.26.0000; Relator: José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 22/05/2006).

“(...) Direito ao silêncio. Impossibilidade do réu ser prejudicado por se manter silente - Possibilidade de ser valorado o teor do interrogatório contra o réu, inexistindo o direito à mentira.” (TJSP; Apelação Criminal 9228927-63.2005.8.26.0000; Relator (a): José Raul Gavião de Almeida; 6ª Câmara de Direito Criminal; Data de Registro: 20/06/2007)

d.4.) O promotor de justiça Andre Wagner Melgaço Reis destaca que “(...) o réu, em seu interrogatório, tem a livre autonomia para trilhar três caminhos. Pode ele confessar a prática do crime, contribuindo com a “busca da verdade real” e, conseqüentemente, com a Justiça, fato que implicará na redução de sua pena, por força da incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Pode, também, ficar em silêncio, fato que não resultará em qualquer prejuízo para ele. No entanto, caso resolva falar perante o Juiz, jamais poderá mentir, pois a lei não lhe confere tal “direito”, cabendo a ele, tão somente, dizer a verdade, pois às partes é exigível o dever de lealdade processual. Dessa forma, caso opte pela mentira, com nítida intenção de induzir o julgador a erro, deve sua pena-base ser majorada, com fundamento em sua personalidade negativa (CP, art. 59), pois reveladora de um caráter distorcido, de ausência de senso moral e de uma índole desviada. (REIS, André Wagner Melgaço. A mentira do réu e a dosimetria da pena. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 21, n. 4670, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/47119>. Acesso em: 8 fev. 2019.

d.5.) Desta forma, entendo devido um aumento de 06 meses à pena base.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Conseqüências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as conseqüências regulares de um tráfico de entorpecente e de uma resistência.

16.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 06 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

17.) Agravantes e atenuantes: o réu é reincidente específico (fls.35/39), razão pela qual exaspero sua pena em 1/5 para fixa-la em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 720 dias-multa, na forma acima descrita.

16.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

19.) Destarte, inexistindo outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena do réu GABRIEL ELISSON FERREIRA DE OLIVEIRA 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e pagamento de 720 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-as definitiva.

20.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, mesmo considerado o tempo de prisão preventiva, nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo.

21.) Apelar em liberdade: o réu não tem direito, eis que respondeu preso ao processo e assim deverá continuar, pois, a apresente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública, e fez emergir o requisito garantia da aplicação da lei penal. A jurisprudência pátria tem entendido que estando o réu preso e sobrevivendo condenação, deve permanecer nessa condição. Expeça-se mandado de prisão.

22.) Por fim, declaro o perdimento, em favor da UNIÃO, dos valores apreendidos.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.R.I.

Santana de Parnaíba, 05 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA